

1501465-33.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Chegando ao local, conhecido ponto de tráfico, avistou o réu tentando fugir com uma sacola na mão, o que gerou suspeita. Após a abordagem, constatou-se que ele trazia consigo entorpecentes e dinheiro. Informalmente, Richard admitiu a prática do narcotráfico (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501465-33.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501465-33.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD STEPHAN MATHIAS ALEXANDRE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dry(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

RICHARD STEPHAN MATHIAS ALEXANDRE foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 10h50, na rua Fernando Colombo, 130, Jardim Salgueiro, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado vendeu, trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de constatação (fls. 13-5), sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 73) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a ilicitude da prova produzida ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão, sob regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 06-9), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls. 13-5), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83-5) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl.05). Sob o contraditório, foi devidamente ouvido (mídia digital).

Os guardas civis municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "faziam patrulhamento ostensivo pela comarca de Mauá, ocasião em que foram acionados para apoiarem uma viatura que fora até ao local dos fatos averiguar uma construção que estaria sendo realizada em local irregular. Em razão de ocorrências anteriormente registradas sabem que o local é convenientemente utilizado como ponto de venda de drogas. Assim, ao adentrarem a via, um indivíduo ora identificado como Richard Stephan Mathias Alexandre, ao avistar a guarnição tentou se evadir correndo, sem sucesso. Abordado no local, em revista pessoal, foi encontrado em seu poder uma sacola contendo porções de maconha, cocaína e crack devidamente embaladas para a venda, além da quantia de R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro. Instado, o indiciado confessou que ali praticava trafico de drogas, sendo o valor encontrado em seu poder proveniente da mercancia de entorpecentes. Aduziu por fim que é morador de rua, sendo a venda de drogas sua forma de sustento" (fls. 03-4).

Em juízo, o GCM Wemerson reafirmou que foi acionado para prestar apoio à equipe que averiguava uma construção irregular em área pública. Chegando ao local, conhecido ponto de tráfico, avistou o réu tentando fugir com uma sacola na mão, o que gerou suspeita. Após a abordagem, constatou-se que ele trazia consigo entorpecentes e dinheiro. Informalmente, Richard admitiu a prática do narcotráfico (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,

enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Registre-se que a abordagem realizada pelos guardas municipais, no caso concreto, encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), o qual regulamentou o § 8º do art. 144 da Constituição Federal e permite o patrulhamento preventivo a fim de "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social" (inciso IV) e "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário" (inciso XIV).

No caso dos autos, ao averiguar uma possível construção irregular em área pública, visando a proteção da população local, os agentes municipais depararam-se com a situação flagrancial.

Além disso, o crime de tráfico de drogas é permanente, de forma que, enquanto atuava para o narcotráfico e trazia consigo os entorpecentes, o investigado encontrava-se em flagrante delito.

Destaca-se, também, a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, diante da autorização prevista no art. 301 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, posicionou-se o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Alegada obtenção de provas por meios ilícitos, posto colhidas por guardas municipais. Impossibilidade. Nulidade não verificada. Pedido de absolvição. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Improcedência. [...] Não se vislumbra, in casu, a alegada obtenção das provas por meios ilícitos, porquanto não só os guardas municipais podem efetuar a prisão em flagrante, como qualquer um do povo pode fazê-lo. É o teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Ademais, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante delito encontravam-se atuantes nos estritos termos dispostos pela Lei 13.022/2014 que regulamentou a competência atribuída à Corporação pelo artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Com a edição de referida Lei, a guarda municipal, no seu território, pode exercer a polícia ostensiva e auxiliar as forças estaduais e federais na segurança pública. Particularmente, no âmbito do flagrante, destaca-se o artigo 5º, inciso XIV, da Lei 13.022/2014. Embora o preceituado neste artigo ultrapasse os limites previstos no artigo 144, § 8º, da CF, entendemos constitucional a previsão. Afinal, tudo o que se relaciona com o município não deixa de ter relação com a tutela dos bens, serviços e instalações do Município onde reside. Ademais, deixou-se cláusula aberta ao final do parágrafo, "conforme dispuser a lei". Diante disso, a guarda municipal tem hoje, dentro dos limites municipais, o mesmo poder da Polícia Militar. [...]" (TJ/SP, Revisão Criminal nº 2017191-29.2020.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme De Souza Nucci, Data do julgamento: 13/07/2020, Data de publicação: 13/07/2020 – grifo nosso).

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Preliminar de nulidade Alegação de incompetência dos guardas municipais para efetuar a prisão em flagrante Descabimento Réu que estava em atitude suspeita Situação de flagrância Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Preliminar rejeitada MÉRITO Pleito de

desclassificação Impossibilidade Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas nos autos Desnecessidade de se surpreender o agente em atos de comercialização Crime de conteúdo variado Condenação mantida PENA Quantidade e variedade de drogas a inviabilizar a aplicação, na fração máxima, do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 Abrandamento do regime prisional Desacolhimento, por maioria Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJ/SP, Apl. Criminal nº 0000508-07.2016.8.26.0544, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/06/2017, Data de publicação: 03/07/2017).

No mesmo sentido, há julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Sem razão a defesa também no ponto em que afirma haverem as guardas municipais exorbitado os limites do patrulhamento preventivo, ao agirem como polícia ostensiva. No caso, não se está a reconhecer o policiamento ostensivo das guardas municipais, mas sim a atribuição de funções essenciais à proteção da população local, bem como de bens, serviços e instalações. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda dos sobreditos bens jurídicos, o agente municipal se depare com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Além disso, a Lei n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevê, expressamente, como princípio mínimo de atuação das guardas municipais, o patrulhamento preventivo (art. 3º, III) e, não obstante dispositivos da referida legislação sejam objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.156, certo é que, até o momento, não houve nenhuma decisão por parte da Corte Suprema, de maneira que a lei em questão continua em pleno vigor no ordenamento jurídico pátrio. Finalmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades (v. g., AP n. 611/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 10/12/2014). Válida, portanto, foi a atuação das guardas municipais e, por conseguinte, a apreensão de substâncias entorpecentes por elas levada a efeito após a realização de revista pessoal no acusado." (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.660 - SP (2017/0324006-0), Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicado em 17/02/2020 - grifo nosso).

"[...] Pois bem, do excerto transcrito verifica-se que o acórdão impugnado não destoia da jurisprudência desta Corte, que entende que a busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. (AgRg no AREsp n. 1.565.524/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 12/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp n. 950.569/MS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/02/2017; e HC n. 525.772/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2019. [...]." (STJ, HC 557934, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Publicado em 17/04/2020).

Descabida, ainda, a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, tendo em vista a afirmação dos guardas municipais no sentido de que o acusado, durante

patrulhamento realizado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, empreendeu fuga, com uma sacola nas mãos, assim que avistou a equipe, de forma que fartamente demonstradas as fundadas razões para a busca pessoal.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça:

"Não há qualquer ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais, que realizavam patrulhamento rotineiro, quando receberam informação sobre a prática do tráfico de drogas no local e observaram o comportamento suspeito do réu, em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, e que por isso o abordaram, sobrevivendo a apreensão de porções de "crack", de cocaína, de maconha, de "ecstasy" e de "lança-perfume". Em se tratando de flagrante delito, o ato dos guardas municipais foi legítimo, conforme previsão do artigo 301, do Código de Processo Penal: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Neste sentido: "Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, §8º, da Constituição da República, sendo delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do artigo 301, do CPP" (STJ, HC 109.592/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18-2-2010, Dje de 29-3-2010). Outrossim, no recente julgamento das ADIs 5948 e 5538, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as vedações trazidas pelo Estatuto do Desarmamento ao porte de armas por guardas civis, reiterando que estes executam atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. E, no plano legislativo, a Lei 13.675/2018 indica as Guardas Municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Conclui-se, pois, que embora a atividade precípua das Guardas Municipais seja a proteção dos bens e serviços do município, bem como do patrimônio público, não há impedimento a que em situações específicas seus integrantes colaborem com a repressão à criminalidade, elevando, por óbvio, a segurança dos munícipes. Ademais, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)", hipótese dos autos" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 1500107-33.2022.8.26.0540, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, julgado em 29.04.2022).

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha as drogas para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base 1/6 acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas - 111 porções de crack (30,25g), 11 de cocaína (10,55g) e 46 de maconha (83,5g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Na segunda etapa, aumento a reprimenda do réu em mais 1/6, diante da reincidência (certidão fl. 24 - proc. 2330-37.2016), totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em ponto de tráfico e em poder dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra: 'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é *contradictio in terminis*, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022).g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo

magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decurso, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimentais no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, Dje de 21/03/2022).

Não incide, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência.

Define-se, assim, a condenação em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

O réu, reincidente, deverá cumprir pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu RICHARD STEPHAN MATHIAS ALEXANDRE, qualificado nos autos, a cumprir pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas (fl. 11) e a perda dos valores apreendidos (fl. 49), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita ao réu (fl. 112). Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA